

第28問

甲は、酒癖が悪く、酔うと是非善悪の判断力を失い妻乙や二人の子供Aに暴行を加えることを繰り返しており、そのことを自覚していた。甲は、ある日、酒を飲み始めたところ、3歳になるAが台所で、茶わんを過って割ってしまったことを見とがめ、Aの顔を平手でたたくなどのせっかんを始めた。甲は、しばらく酒を飲みながら同様のせっかんを続けていたところ、それまで泣くだけであったAが反抗的なことを言ったことに逆上し、バットを持ち出してAの足を殴打し重傷を負わせた。甲は、Aが更に反抗したため、死んでも構わないと思いつつAの頭部をバットで強打し、死亡させた。乙は、その間の一部始終を見ていたが、日ごろAが乙にも反抗的態度をとることもあって、甲の暴行を止めようとはしなかった。

甲については、逆上しバットを持ち出す時点以降は是非善悪の判断力が著しく減退していたとして、甲及び乙の罪責を論ぜよ。

(旧司法試験 平成13年度 第1問)

本問は、長崎地判平4.1.14【百選 I 36】を素材としているものと思われる。もっとも、途中から殺意を生じている点で、同判決とは事案が異なる。

第1 甲の罪責

- 1 甲のAに対する一連の暴行は殺人罪（199）の構成要件に該当する。
- 2 もっとも、甲が殺意を抱きバットを持ち出した時点では、是非善悪の判断力が著しく減退していたから、39条2項の限定責任能力状態にあり、完全な責任を問うことができないのではないかが問題となる。いわゆる原因において自由な行為の問題である（**論点** 原因において自由な行為  旧H13-1）。

構成要件モデルからは、限定責任能力下の故意行為が問題となっている以上、39条2項の適用を排除するのが難しい。

責任モデルからは、結果行為が一連の意思の実現過程であると評価される場合には、完全な責任を問うことができるが、本問では、原因行為時には、殺意がなかったのだから、一連の意思の実現過程とみることができず、殺人罪として完全な責任を問うことはできない。

したがって、責任モデルからでも、39条2項の適用を排除することはできない。

なお、殺意が生じたのは限定責任能力下であるから、一連の意思の実現過程とみることができるとすれば、傷害致死罪（205）の限度だろう。仮に、これも成立させるとすれば、殺人罪に吸収されることになる。

 総合 88 頁  論証 33 頁

第2 乙の罪責

- 1 乙については、不作為の共犯（60）の成否が問題となる（**論点** 不作為による共犯  司H26,予R3,旧H13-1）。
- 2 この点に関しても、様々な見解が主張されているが、原則として、共犯となるという説が通説である。判例もこの立場に立つと解されている（大判昭3.3.9、大判昭19.4.30、最判昭29.3.2など）。

この見解によれば、本問でも、乙は傷害致死罪の幫助犯（205、62 I）となる。

なお、甲と乙の間には意思連絡がないから、いわゆる片面的幫助の可罰性が問題となるが、これを肯定するのが判例である（大判大14.1.22、東京地判昭63.7.27【百選 I 87】）（**論点** 片面的幫助）。

 総合 157 頁  論証 64 頁

 総合 145 頁  論証 58 頁

答案構成

第 1 甲の罪責について

1 殺人罪成立（199）



39条2項の適否



2 原因において自由な行為



原因行為から実行行為まで意思が連続し両者が同一の意思に貫かれた一個の行為と評価し得る場合には、完全な責任を問うる



3 あてはめ



4 39条2項適用

第 2 乙の罪責について

1 傷害致死罪（205）の単独正犯又は共犯の成否



2 共同正犯（60）不成立



単独正犯不成立



3 幫助犯（62 I）の成否



①作為義務、②作為の可能性・容易性、③因果関係



あてはめ



片面的幫助の肯否



肯定説



4 乙は、傷害致死罪の幫助犯の罪責を負う

第1 甲の罪責について

1 甲は、一連の行為によって、Aを死亡させており、また、死んでも構わないと思いつつバットでAを殴打し死亡させているので、「人を殺した」ものとして、殺人罪（199条）が成立する。

ここで、バットを持ち出す時点以降は是非善悪の判断力が著しく減退しているから、限定責任能力状態にあったといえ、39条2項により刑が必要的に減軽されるとも思える。

しかし、甲は酔うと是非善悪の判断力を失い、暴行を加えることを自覚しているのだから、このような結論は妥当でないのではないか。そこで、甲の行為にいわゆる原因において自由な行為の理論を適用できないかが問題となる。

2 この点について、原因行為を実行行為とみた上で、原因において自由な行為は自己の責任無能力状態を道具として利用するもので、間接正犯類似の構造をもつものとする見解がある。

しかし、本問のような限定責任能力状態下の自己の故意行為は道具とはいえないから、およそ原因において自由な行為の理論を適用できないこととなり、妥当でない。

責任能力が必要とされている根拠は、犯罪結果が責任能力状態下の意思決定に基づいて実現したときにはじめて非難が可能であるという点にある。

そうだとすれば、自由な意思決定に基づく原因行為と実行行為（結果行為）とが因果的に結び付いている場合、実行行為は責任能力状態下の

1

意思決定の実現過程にほかならないことから、実行行為時に責任能力があったか否かにかかわらず、完全な責任を問得る。

そして、原因行為と実行行為とが因果的に結び付いているといえるためには、原因行為から実行行為まで自由な意思決定に基づく意思が連続し、両者が同一の意思に貫かれた一つの行為と評価し得ることが必要である。

3 本問では、酒を飲み始めるという原因行為時には、甲に殺意がなかったのだから、同一の意思に貫かれた一つの行為とみることはできない。そのため、甲に殺人罪として完全な責任を問うことはできない。

4 よって、甲に39条2項の適用があり、殺人罪について刑の必要的減軽がなされる。

第2 乙の罪責について

1 乙は甲がAに暴行を加えていることを認識しつつ、これを黙認していることから、傷害致死罪（205条）の単独正犯ないし共犯となることが考えられる。なお、乙には殺意（38条1項）までは認め難いから、殺人罪の単独正犯ないし共犯となることはない。

2(1) まず、乙と甲との間にAに対する暴行についての意思連絡はないから、「二人以上共同して犯罪を実行した」ものとして、共同正犯（60条）となることはない。「共同」したといえるためには、共同犯行の一体性を基礎づける意思連絡が要求されるからである。

(2) では、乙が単独正犯と幫助犯（62条1項）のいずれとなるか。

単独正犯とは構成要件の実現過程を支配した者をいうと解すべきと

2

ころ、乙は、甲の暴行に加担したわけではなく、これを黙認したにすぎないから、積極的関与がない。そのため、構成要件の実現過程を支配したものとは認められない。

したがって、乙は傷害致死罪の単独正犯とはならない。

3(1) そこで、傷害致死罪の幫助犯の成否を検討する。

「幫助」とは、正犯の実行行為を物理的又は心理的に促進し、容易にすることをいうから、そのような関係が認められる限り、これを不作為形態によって実現することも可能である。

その成立要件としてまず、①作為義務の存在が必要である。刑罰法規の明確性を確保する観点から、処罰範囲を限定する必要があるからである。作為義務は、法令・慣習・契約のみならず、先行行為の存在、排他的支配の設定（具体的依存性）等の諸事情を総合的に考慮してその有無を判断すべきである。そして、法は無理を強いるものではないから、②作為の可能性・容易性が必要である。最後に、③結果との因果関係が要求される。とはいえ、正犯と異なり、作為による幫助が正犯の実行行為を促進し、容易にすることで足りるとされていることの均衡から、犯行を確実に阻止できなくても、それを困難にできた可能性があれば足りると解する。

(2) まず、①乙はAの監護権者であり、Aを監護する法律上の義務がある（民法818条1項、820条）。また、Aは3歳と幼く、甲による暴行から自力で逃れるなどということは困難である。さらに、室内には甲とAのほかは乙しかいないものと思われ、Aの生命身体の保護

3

は乙に依存する部分が大き。

これらの事情を総合的に考慮すれば、乙に作為義務が肯定される。具体的には、助けを呼ぶなどの期待された作為を行う義務が認められる。

また、②甲は乙に対して暴行を加えることもあったが、少なくとも助けを呼ぶという程度の行為は可能であって、また容易であるから、乙が甲の行為を阻止し得る可能性及びその容易性も認められる。

最後に、③上記のように乙が助けを呼ぶなどして甲の行為を間接的にでも阻止すれば、甲はAに対する暴行を思いとどまった可能性は否定できず、犯行を確実に阻止できなくても、少なくともそれを困難にできた可能性はあったものと考えられる。

(3) よって、乙はAに対する傷害致死罪の幫助犯となり得る。

(4) もっとも、上記のように、乙と甲との間に意思連絡がないから、仮に、幫助犯の成立に正犯との間の意思連絡が必要と解すれば、幫助犯の成立は認められないことになる。

しかし、幫助犯は正犯の犯行を心理的又は物理的に促進し、容易にすることで足りるのであり、共同正犯のような共同犯行の一体性は要求されないから、必ずしも意思連絡は必要ないものと解すべきである。

したがって、上記意思連絡がないことは、幫助犯の成立にあたって障害とはならない。

4 以上から、乙は傷害致死罪の幫助犯の罪責を負う。 以上

4